

境外自营机构设立贸易实体开展境内期货 投资的合规探讨与监管应对

■ 姜 哲

[摘 要] 2015年伊世顿、司度公司操纵境内股票和期货市场案件曝光以来,境外自营机构以贸易实体之名在境内开展证券期货投资的现象被社会各界广泛关注。该文结合这类业务的历史发展脉络,在现有监管框架下对其进行合规探讨。研究提出,境外自营机构在华设立外商投资实体,大量开展与其登记的主营业务不符的期货投资,这种现象存在历史的复杂性、法规的局限性和执法的挑战性。该行为虽在结果层面与现行的监管思路相悖,但基于现有法规进行从严处罚又存在难度。建议优先形成处置方案,将此类开展期货投资的境外自营机构所设实体纳入金融准入监管,由相关部门牵头梳理现有法规,提供司法解释,明确业务定性,限制增量业务,妥善处置存量业务,逐步引导境外自营机构通过合法渠道入市。中长期应制订详细的外商投资负面清单监管指引,将境外自营机构在境内的准入、汇兑、交易等行为纳入全流程监管,妥善处理行业发展与金融稳定、资本流动、国家安全和贸易自由化等目标的关系,推动境内资本市场法制化对外开放。

[关键词] 期货市场;期货与衍生品法;外商投资法;高频交易;自营机构

[中图分类号] F746.16 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-169X(2023)04-0031-09
DOI: 10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2023.04.003

[基金项目] 北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院青年项目(XYYZS2020003)。

[作者简介] 姜哲(1990—),湖北武汉人,武汉大学董辅初经济社会发展研究院,博士研究生,研究方向为资本市场开放与衍生品交易。

一、引言

2015年境内资本市场巨幅波动期间,证券期货监管部门相继修改融资融券规则,调整交

易手续费,对具有程序化交易特点、频繁申报或撤销申报、涉嫌影响证券交易价格等可疑账户采取限制措施^①,首次将程序化交易^②与市场巨

^①参见上交所、深交所和中金所网站。2015年7月31日,上交所和深交所根据《交易规则》,对频繁申报或频繁撤销申报,涉嫌影响证券交易价格或其他投资者投资决定的24个账户采取了限制交易措施。8月3日,分别发布通知对融资融券交易实施细则进行修改,明确规定投资者在融券卖出后,需从次一交易日起方可通过买券还券或直接还券的方式偿还相关融券负债。中金所自8月3日起将股指期货手续费调整为交易手续费和申报费两部分,将沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货交易手续费标准降为成交金额的0.023%,根据客户沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货各合约的申报数量收取申报费,每笔申报费一元。对从事股指期货套利、投机交易的客户,单个合约每日报撤单行为超过400次、每日自成交行为超过5次认定为“异常交易行为”。

^②该文在描述贸易实体在境内的投资行为时,不严格区分程序化交易、算法交易、自动化交易等表述差异,以程序化交易泛指通过电子计算等软硬件技术优势在二级市场获利的交易方式。

幅下跌关联起来。此后,由公安部会同相关部门对可疑账户开展全面调查,并确认张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司(以下简称“伊世顿”)、司度(上海)贸易有限公司(以下简称“司度”)等企业有重大嫌疑,被正式立案。2017年,上海市第一中级人民法院就伊世顿非法利用技术优势操纵期货市场案公开审判^①,宣判被告单位伊世顿,被告人高燕、梁泽中、金文献操纵期货市场和金文献职务侵占成立,对伊世顿以操纵期货市场罪判处有期徒刑3亿元,没收违法所得3.89亿元。华鑫期货涉嫌违法违规,包括实际使用非本公司购买或开发的交易系统传递伊士顿的交易指令,未对该系统进行交易的客户账户资金和持仓进行验证,不符合期货公司审慎经营和风险管理要求,未建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度,风险管理和内控存在较大缺陷,被上海证监局没收违法所得1008.9万元并罚款1008.9万元^②,此后还相继被中金所行政处罚和中期协纪律惩戒^③。2020年,中国证监会与司度、富安达基金管理有限公司、中信期货有限公司、北京千石创富资本管理有限公司、国信期货有限责任公司等五家机构及其相关工作人员,就其涉嫌违反账户管理有关规定及资产管理业务有关规定的案件达成行政和解^④。根据申请人在涉嫌违法行为中所得金额的不同,五家申请人分别缴纳行政和解金6.7亿元、180万元、1000万元、235万元、100万元,并按协议要求采取必要措施加强公司内控管理,中国证监会依规终止对申请人有关行为调查和审

理。此前,中国证监会还对涉案的中信证券等机构实施行政处罚^⑤。

轰动一时的境外机构操纵境内证券期货市场案虽已告结,却将以伊世顿、司度为代表的境外机构所设境内贸易实体长期在境内开展二级市场程序化交易的内幕公之于众。据财新周刊报道,境内目前仍存在大量类似伊世顿、司度这类境外机构设立的贸易实体,假借贸易之名,在境内开展与所登记主营业务无关的二级市场投资。伊世顿、司度事件后,监管部门的审慎管理措施一定程度限制了高频程序化交易在金融期货和股票现货领域的发展。目前,这类自营机构以开展境内商品期货程序化交易为主(岳跃和王石玉,2022)。境外自营机构针对目前中国关于非居民参与境内期货交易时在准入、汇兑、行业监管等方面的法规和监管漏洞,利用“Trading”存在“贸易”和“交易”两种中文翻译差异,在华设立贸易业务为主的外商投资实体,用自有资金开展二级市场程序化交易并获利颇丰(姜哲,2021)。这类境内贸易实体的交易行为受境外机构影响或指导,其本质是境外自营机构通过设立贸易实体绕开境内期货市场外资准入要求而直接参与境内二级市场交易。

事实上,由于境内期货市场早年乱象丛生,也考虑到衍生品交易的高杠杆特性,参考其他经济体期货市场开放的经验教训,境内金融监管部门一直将期货市场对外开放作为排位相对靠后的开放选项(姜哲,2019)。时至今日,境外投资者参与境内股指期货和期权仍仅限于基于

①参见上海市第一中级人民法院(2016)沪01刑初字第78号刑事裁定书(罚金货币为人民币)。

②参见《中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚事先告知书》(沪证监处罚字[2019]9号)、《中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书》(沪[2019]16号、沪[2019]17号、沪[2019]18号)。

③参见中国金融期货交易所《纪律处分决定书》([2020]1号)和《关于对华鑫期货有限公司、李俊作出纪律惩戒的决定》(中期协字[2020]109号)。

④参见《中国证监会关于与司度(上海)贸易有限公司等五家机构及其有关工作人员达成行政和解的公告》(证监会公告[2020]1号),和解金支付货币为人民币。

⑤参见《中国证监会行政处罚事先告知书》(处罚字2017[57]号、处罚字2017[58]号、处罚字2017[59]号)。

实需的套期保值^①；由证券公司作为试点中介的跨境收益互换，其参与境内衍生品市场的主要客户以境外机构投资者为主^②；境内商品期货市场系统地对外开放始于2018年原油等特定品种模式^③；直至2021年，中国证监会等三部门才正式允许QFII投资者投资境内商品期货期权^④。总的来看，当前中国在开放期货市场的节奏上仍相对谨慎，且所有渠道式开放的参与主体均为需在境内交易所或通过银行注册/备案为境外投资者身份，从而被穿透监管。

伊世顿、司度案件虽已尘埃落定，但这类外商投资贸易实体在境内大量存在且仍正常开展交易，尤其是深度参与境内商品期货投资（岳跃和王石玉，2022），有必要从法律角度对相关现象的合规性进行探讨，结合行业实际发展情况统筹研究合理妥善的应对方案，逐步完善现有监管框架，支持境内期货市场健康发展，并维护对外开放的良好形象。

二、外商投资贸易实体参与境内期货市场的合规探讨

外商投资贸易实体参与境内期货市场一般包括以下步骤：第一，境外母公司（多为自营机构）在华设立外商投资企业（FDI），这一过程受地方招商引资鼓励，即使在“外资三法”时期，申请流程也十分简单甚至享受诸多政策便利，地方商务部门也不具备甄别企业是否真实经营的能力。随着《外商投资法》和《外商投资法实施条例》出台，外商投资准入程序进一步简化，商务部门退出前置审批，外商投资企业在市场监管部门取得营业执照即可在银行办理外汇登

记。第二，以外债或接受FDI资本金汇入等形式，由境外母公司向境内主体汇入资金，购买证券期货交易所需软硬件设备等。其中，部分外商投资贸易实体会在设立初期开展少量真实的贸易业务，以形成流水和人民币利润进行再投资；少数外商投资实体完全由会计师虚构符合主营业务的流水。第三，以贸易实体在现货端需开展套期保值对冲风险等正当名义，在期货公司开立账户，并逐步将具有一定贸易真实背景的套期保值业务拓展至纯粹的期货投机交易甚至程序化交易。上述操作涉及了外商投资企业设立、资金汇兑和使用、期货交易等多部门的多项监管法规，因此，要讨论这一现象的合规性，需从事实结果出发，按照“上位法优于下位法、新法优于旧法”的原则，参考所涉各领域的监管法规逐一讨论。

（一）事实结果违反现行监管思路

从事实结果看，境外自营机构设立的贸易实体在境内开展期货交易，事实上规避了当前关于非居民参与境内衍生品交易的所有限制。这类贸易实体使用自有资金并借助外商投资企业身份，享受了国民待遇无差别参与境内期货交易。若这一事实结果存在合法性且应受到法律保护，则目前所有的各种存在限制性要求的渠道式开放模式就没有存在意义，广大境外投资者均可遵循此模式，先设立外商投资企业再开展境内期货投资，那么境内期货监管部门也无需履行复杂的报批流程，逐项报经国务院同意开展某一类型的期货品种开放试点。因此，这类通过设立外商投资贸易实体实现境内期货

①参见《合格境外机构投资者参与股指期货交易指引》（证监会公告〔2011〕12号）和《中国证监会关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与金融衍生品交易的公告》（证监会公告〔2021〕24号）。

②参见《关于证券公司开展大宗商品业务有关事项的复函》（证券基金机构监管部部函〔2014〕1353号）。

③参见《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》（证监会令第116号）。

④参见《中国证监会关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与金融衍生品交易的公告》（证监会公告〔2021〕24号）。

交易的行为与现行的境内衍生品市场开放和监管思路相违。

(二)涉嫌违反外商投资管理相关规定

第一,涉嫌违反外商投资负面清单禁令。参考《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》第八条“《外商投资准入负面清单》中未列出的文化、金融等领域与行政审批、资质条件、国家安全等相关措施,按照现行规定执行”,以及当前国务院证券期货监管部门对境外投资者参与境内期货市场的行政审批和资质条件,境外自营机构通过设立外商投资企业,转换为居民身份规避负面清单中金融领域的资质条件开展金融领域投资,本质上是在进行外商投资负面清单中的限制性投资(套期保值除外)。若确认外国投资者投资负面清单规定所禁止投资的领域,或外国投资者投资活动违反负面清单规定的限制性准入特别管理措施的,应按照《外商投资法》第三十六条予以处理。

第二,涉嫌未履行间接投资的信息报告义务。根据国际投资的法律定义(季烨,2011),外商投资企业若开展境内证券期货投资属间接投资而非直接投资。《外商投资法》第三十四条所确定的外商投资信息报告制度明确了主管部门、报送途径和“确有必要”的原则,在法律责任章节明确规定了投资者违反信息报告义务的法律后果,且《外商投资信息报告办法》第二条明确要求外国投资者间接在中国境内进行的投资活动,应由外国投资者或者外商投资企业向商务主管部门报送投资信息。理论上,上述外商投资贸易实体也应就其开展的间接投资履行信息报告义务,但现实中并不保证相关贸易实体都切实履行了该信息报告义务。

第三,涉嫌违规经营。从相关外商投资贸易实体在境内注册的主营业务范围看,主要包括贸易信息咨询、羊毛、天然橡胶、化工原料、钢材、木材、饲料批发等,经营的现货领域多数与境内商品期货市场的上市品种重叠,但均不包含二级市场证券期货投资、代客交易或理财等金融业务。考虑到这些贸易实体在二级市场实际取得的利润规模,其投资行为已成为事实上

的主营业务,但相关项目又属于外商投资负面清单内容而无法直接进行登记,因此造成上述贸易实体大量开展非登记主营业务的事实,可能涉嫌违规经营。

(三)是否违反外汇管理规定存在争议

第一,若使用资本金、前期费用等直接开展期货投资违反现行外汇管理规定。根据《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条要求,外商投资企业从境外获得的资金(如资本金、外债、境外上市募集资金、前期费用等,人民币参照外汇管理规定执行)及使用应符合外汇管理相关规定。外商投资企业外汇收入及其结汇所得人民币资金应在企业经营范围范围内使用,并符合真实自用原则;除另有明确规定外,外商投资企业外汇收入及其结汇所得人民币资金不得直接或间接用于证券投资。因此,外商投资企业若使用资本金、前期费用等用于企业经营范围以外的二级市场投资,在定性为非法经营的同时,也违反了现行外汇管理规定。

第二,合法经营产生的人民币利润开展期货投资存在争议。现行外汇管理规定主要针对跨境交易和货币兑换等环节,若外商投资企业使用其生产经营过程中产生的人民币利润进行再投资,现行外汇管理规定难以对其进行有效执法。若认定该外商投资企业适用《外商投资法》第四条享有国民待遇,则其人民币利润的再投资完全合法,外汇管理法规在汇兑环节予以支持;若认定该外商投资企业期货投资适用负面清单内容,即认为其二级市场投资规模较大已事实上违反登记主营业务,此时外汇管理政策不支持其前述行为,在后期资金汇兑等环节应进行限制。换言之,外汇管理法规原则上并不直接对外商投资企业合法经营的人民币利润再投资具有绝对处罚权,也无法直接对该行为进行限制,除非前述准入和经营行为不符合现行法律,外汇管理部门才能限制其投资后续所涉资金汇兑业务。

第三,相关业务经办主体可能需承担连带责任。外商投资企业取得营业执照后开户、资金结汇汇入、取得相应会计/审计/完税等凭证、

资金购汇汇出等流程中,可能涉及业务经办银行、会计师事务所、律师事务所、咨询公司等多个业务经办或合作主体。银行在为外商投资企业办理汇兑过程中,发现外商投资企业明显使用资本金或前期费用进行期货投资的,应按照规定向相关部门反映并不为其办理后续资金汇兑业务。发现外商投资企业利润与同类型直接投资企业利润率明显不同的,按照“了解你的客户”(KYC),银行应对其进行真实性调查,银行若不执行相关审慎要求或明显发现相关凭证造假/存疑而仍协助办理汇兑业务的,可能需承担连带责任。相关会计师事务所、律师事务所、咨询公司等协助外商投资贸易实体虚构贸易背景、银行对账单、公司流水、财务报告等,应由其行业主管部门依法予以惩治,对伪造交易的主体,可依《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款、第二十条第一款进行处罚。情节严重的,包括但不限于收受贿赂、骗汇、逃汇等,可追究其刑事责任。

(四)是否违反期货领域现行法规存在争议

第一,境内期货市场对居民无资格准入要求。境内期货市场不属于特殊准入行业,尽管准入要求中包括须符合国家、行业的有关规定,但除对投资者有适当性要求外,未对境内企业的参与设置任何特殊准入门槛。若该贸易实体已事实上合法合规取得与境内居民等同的身份地位(《外商投资法》第九条将外商投资企业视为享有国民待遇的境内居民),自律监管部门可能默认其已经符合相关规定,则其参与期货交易不涉嫌违反现行规定,这在路易达孚、可口可乐等外商投资企业过去深度参与白糖期货,大型跨国服装企业参与棉花棉纱期货管理企业经营风险的正面案例中便可获得佐证,而实践中的风险管理头寸和期货投机并没有严格的标准可供区分。至于其是否违反外商投资中的负面清单限制,则不属于期货监管法规的解释范畴。

第二,上位法缺乏明确的禁止性表述。当前国务院期货监管部门的执法依据主要包括上

位法、规范性文件和各自律监管法规等,但最新发布的《期货与衍生品法》并未对境外机构或有境外背景的境内机构参与境内期货市场作任何原则性表述,其对于投资者的区分也严格按照境内和境外划分,未考虑投资者真实的背景和属性,而现行的规范性文件和自律监管实施细则原则上应据此上位法更新执行。因此,若按照现行的期货监管法规来惩处这类外商投资贸易实体直接或间接开展境内期货投资的行为缺乏上位法依据,自律监管部门也无上位法依据直接限制其开户交易。只有当个别贸易实体开展明显与登记业务不符的期货交易被识别,且相关交易策略或行为已违反现行的期货市场监管规定的,如存在操纵市场嫌疑等,自律监管主体才可根据操作指引等对其处以市场禁入、禁止相关品种交易、罚款等处罚。情节严重的,由相关部门确认后参考《刑法修正案(十一)》第一百八十二条及罚则执行。

第三,自律监管主体未履行审慎监管义务。从财新周刊报道看,境内的自律监管主体(姜哲,2017)对这类贸易实体深度参与境内期货市场长期知情,且境内交易场所均具有穿透监管能力可掌握所有投资者的全部信息(姜洋,2020),但一直未对相关行为进行任何实质性约束或规范,反而与相关贸易实体开展多种形式的合作(岳跃和王石玉,2022),间接助长了境外自营机构通过这类贸易实体投资境内期货市场的势头,向境外自营机构群体传递了错误信号。自律监管主体未主动履行审慎监管的义务可能受以下原因影响:一是外商投资贸易实体的主营业务与该自律监管主体的挂牌品种密切相关,难以有效甄别是实际生产经营中的风险管理需要还是投机交易。二是相关交易以自营为主,不涉及代客理财,少有合同纠纷,也不适用《九民纪要》所关注的金融纠纷类型^①,可能造成的社会负面影响较小,受关注度不高,主动监管动力不足。三是相关交易以程序化为主,不少为高频交易,所带来的流动性和手续费收入,

^①参见《全国法院民商事审判工作会议纪要》(法[2019]254号)。

使其与自律监管主体形成一定程度的利益捆绑。四是鉴于行业历史发展的特殊性,早年境内期货市场成交萎靡,为支持境内期货市场发展,出于提高品种活跃度、与国际接轨、支持本土程序化交易和场外业务发展等考虑,境内期货市场曾非公开地为个别境外主体创造过“一事一议”的试点条件,这种非制度化的引进模式具有时代的特殊性,也一定程度制约了后期自律监管主体的主观能动性。

此外,考虑到境外自营机构的境内贸易实体在技术上拥有的绝对性排他优势和接近全市场一半的盈利份额(姜哲,2021),其是否涉嫌滥用市场支配地位构成垄断也存在争议。目前境内尚无可供参考的审判案例,且由上述分析易知,在现实中从自律监管部门对此类涉嫌垄断行为的调查、取证等也存在较大难度,境外监管部门对金融机构的反垄断处罚是否适用于此类垄断地位的定义也存在争议^①。而金融稳定方面,贸易实体虽已构成事实上的非持牌机构开展金融业务,但鉴于《中华人民共和国金融稳定法(草案征求意见稿)》并未专门描述此类情形,贸易实体开展期货投资是否构成法律意义上的非持牌机构经营金融业务,尚没有权威的解释可供参考。此外,贸易实体的自有资金投资不涉及委托和借贷关系,其影响境内金融稳定的渠道主要通过程序化交易间接影响金融市场,对这类业务如何定性尚待法规补充完善。

三、妥善应对相关行为的潜在风险

为有效统筹境内资本市场对外开放,防范套利风险导致系统性风险,避免重蹈伊世顿、司度案覆辙,影响境内金融稳定,建议境内监管部门从风险处置和完善法规两方面对相关行为进行规范。就风险处置而言,应兼顾以下三点:一是明确相关业务的法律定性,二是操作中如何妥善处理存量和增量业务,三是如何促进行业健康发展。

境外自营机构设立外商投资贸易实体深度参与境内金融市场本质上与蚂蚁集团使用商业类经营性牌照开展小贷等金融业务,从而规避境内金融业务需持牌经营的做法(王琦,2022)类似,根本目的都是为了规避某一特定领域的持牌要求,来开展在当前金融监管框架下暂不允许或需较长审批时间的金融业务(含自营交易)。参考中国金融管理部门联合约谈蚂蚁集团提出的五点整改要求^②的风险处置原则和国际上关于管理非居民投资的经验^③,该文对外商投资贸易实体境内开展期货投资并积累高额收益的行为事实研提以下应对原则:

一是明确法律定性。按照上述分析,外商投资贸易实体参与期货交易是否违规取决于该行为是否违反负面清单,但目前外商投资相关法规较为抽象,并未细化到可一一对应的标准,建议由行业主管部门牵头明确相关主体的违规经营标准,并比照相关标准判断不同的外商投

①参见欧盟对瑞银、巴克莱等银行的反垄断处罚, Antitrust: Commission fines UBS, Barclays, RBS, HSBC and Credit Suisse € 344 million for participating in a Foreign Exchange spot trading cartel (2 December 2021)。

②参见《中国人民银行副行长潘功胜就金融管理部门约谈蚂蚁集团有关情况答记者问》(2020年12月27日)和《中国人民银行副行长潘功胜就金融管理部门再次约谈蚂蚁集团情况答记者问》(2021年4月12日)。整改要求包括:一是回归支付本源,提升交易透明度,严禁不正当竞争。二是依法持牌、合法合规经营个人征信业务,保护个人隐私。三是依法设立金融控股公司,严格落实监管要求,确保资本充足、关联交易合规。四是完善公司治理,按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动。五是依法合规开展证券基金业务,强化证券类机构治理,合规开展资产证券化业务。

③欧盟监管(非居民)对冲基金以合格投资者为主,例如,爱尔兰为欧盟主要的对冲基金注册国,对冲基金可作为专业投资者基金(PIFs)或合格投资者基金(QIFs)设立,通常是作为QIFs成立,爱尔兰监管机构(爱尔兰金融服务监管局IFSRA)可能会对PIF施加杠杆率和集中度限制,但不会对QIF限制。

资贸易实体的违规程度,对于明显违规的贸易实体,应按照对应罚则进行处理。

二是处置存量业务。建议由期货监管部门牵头成立风险处置小组,研究尽可能与此类开展二级市场投资的外商投资贸易实体达成行政和解,允许其在认缴一定比例和解金后注销原贸易实体以退出中国市场。境外自营机构有进一步在华开展证券期货投资意向的,应按现有的合法入市渠道,申请各渠道的准入牌照,在此身份转换过程中,各监管部门可在操作中适当给予支持。逾期不和解或不停止其交易行为的,待明确法律定性后,由相关部门依法提请履行处罚程序。

三是控制增量业务。从境内期货市场现有的穿透式监管能力看,期货交易所和期货公司实际上对每一家参与相关期货品种交易的投资者背景情况了如指掌,这是客观上阻断增量业务发生的有效保障。风险处置小组应指导期货交易所等自律监管部门加大对新增的外商投资贸易实体开展期货交易的监察力度,对于交易规模明显超出其风险管理需要的,应劝勉其暂停交易。期货公司在为外商投资贸易实体办理开户的过程中,应劝勉客户放弃开展期货投机交易,尤其是程序化交易甚至高频交易。

四是外资权益保护。对于已缴纳行政和解金的外商投资贸易实体应在指定日期前到相关部门注销其在外设立的外商投资企业,并持证券期货监管部门无异议函和会计师事务所出具的审计报告等材料到银行办理资金汇出。对于还有进一步在华投资意愿且已申领相关准入牌照的机构,如已获得QFII资质的机构、已在期货交易所备案成为特定期货品种的境外投资者,可依法^①开立相关NRA账户,期货交易所可为其办理非交易过户,银行可在无异议函基础上,为其办理同名不同账户间资金划转,资金不用实际出境。

五是化解投资顾虑。境外自营机构不愿主

动选择QFII等模式入市的原因,除了资格申请流程较长、程序复杂外,主要在于托管制度对透明度的要求,而自营机构的交易策略是其盈利的核心竞争力。因此,要引导境外自营机构在合法渠道有序开展境内证券期货投资,需优先解决其对于信息泄露,尤其是核心交易策略和系统代码等泄露的顾虑。建议对从事程序化交易的境外投资者制订专门的监管要求,在其登记为程序化交易商或高频交易商后,可豁免部分信息报送的义务,免除其向托管机构、自律监管部门提交代码底稿和交易策略等(需配合调查等特殊情况下除外),并为引导其合法合规入市创造有利的政策条件。

六是限制超高频交易。鉴于短期内完善所有被涉及的法规存在较大难度,且包括个别贸易实体是否实际构成行业垄断、高频交易是否会显著影响金融稳定等都存在较大争议,考虑到超高频交易对支持实体经济发展的意义较为有限(姜哲,2021),结合现有文献中关于高频交易对金融稳定的研究(巴曙松和王一出,2019;雍晨,2019),建议可暂时限制一部分超高频交易,限制标准和阈值由国务院期货监管部门结合境内证券期货市场实际情况研究决定,各期货交易所可通过设置减速带等多种形式实现降速和限流(姜哲,2017)。

四、完善相关法规

风险处置作为解决这一现象的手段,还需要中长期完善的法规作为有效监管的保障。境外自营机构通过《外商投资法》中准入前国民待遇加负面清单,绕开境内金融监管部门对境外投资者参与境内金融市场的准入限制,套换身份成为享受居民待遇的境内独资企业或境内合资企业,自由参与境内金融市场二级交易尤其是商品期货高频交易。这类交易者的出现,凸显出当前相关监管框架存在漏洞的事实,建议从准入、汇兑、交易等全流程对现行法规予以完

^①参见《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》(中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2020〕第2号)和《国家外汇管理局关于境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2015〕35号)。

善,以禁止未来出现更多类似机构竞相效仿。

第一,从准入管理角度,相关贸易实体的行为与现行的金融市场对外开放总体方针相悖,其期货投机业务,不论代客还是自营,原则上均属于《外商投资法》和市场监督管理总局已明确的外商投资企业负面清单内容,其投资行为应获得相关金融监管部门批准后持牌开展。但实际操作中,鉴于企业登记的主营业务为符合现行法规的贸易业务,而前置部门法规又缺乏对开展负面清单投资的定性标准,对从事非主营业务的判定缺乏统一尺度,在交易端期货交易对于判定其是否为过度套保等也无上位法依据。因此,建议在下阶段完善外商投资管理法时,有关部门应在法规中明确外商投资企业从事有争议的负面清单投资时,构成事实上主营业务的定性标准,如贸易实体在期货市场盈利达到注册资本金一定比例的,可认定其投机交易已构成事实上的主营业务,须视为外商投资企业直接参与境内资本市场,参照负面清单进行处罚,而低于相应标准的套期保值交易应作为正常的经营需要予以支持。同时,应尽快明确外商投资企业“再投资或间接投资”的法律界定标准,以便后置环节的法规进一步解释和完善。

第二,从外汇管理角度,除限制资本金、前期收入等资金类型开展二级市场投资外,现行外汇管理法规并未明确外商投资企业在境内经营所得人民币利润的使用范围。按照现行的外汇管理框架,若外商投资企业的身份合法且其二级市场投资来源为境内合法经营所产生的人民币利润,则不涉及汇兑管理相关内容,外汇管理规定难以进行限制,但企业后期换汇和资金汇出直接涉及外汇管理权责,有必要在现行外商投资管理框架下,外汇管理部门加强对银行办理资金汇兑业务的真实性审核要求,会同财政、审计、税务等部门加大对资金汇兑环节构造虚假贸易、伪造审计/会计报表等行为的处罚力度,在保障真实经营的外商投资企业利润自由汇出入

的前提下,加大对异常规模利润汇出的管理。

第三,从期货监管角度,期货交易所对所有投资者情况了如指掌,可通过“看穿机制”了解投资者的全部交易行为,分析其交易目的,而期货公司是贸易实体直接接入交易所开展交易的载体,因此,期货自律监管主体是最有能力在源头制止发生、最有能力正确判断交易性质的机构,建议后期在《期货与衍生品法》操作指引更新中,强调贸易实体在进入期货市场时应以套期保值管理风险为目的,不鼓励以外商投资企业形式开展期货投机。若未来外商投资法规明确了贸易实体等参与境内金融市场构成事实上的主营业务的比例标准后,期货自律监管部门也应及时更新法规,从期货行业监管角度对明显超过相关盈利比例的外商投资企业进行限制。

第四,从行业发展角度,此类外商投资贸易实体的发展现状说明,境内证券期货监管部门早期希望通过引进境外自营机构带动境内程序化交易、私募理财、做市业务等领域发展的初衷几近落空,境外自营机构通过独立的贸易实体,以自有资金交易,不寻求为境内投资者代客理财分享其技术优势带来的超高收益率,更没有带动本土CTA行业发展。因此,建议转变默许境外自营机构以独资实体形式在境内展业的思路,参考证券、基金等行业外资股权渐进变更的经验,先期支持中外合资的投资机构在合规前提下有限开展试点业务。例如,引导境外自营机构与境内私募成立合资公司或以境内资产管理机构名义联合发行CTA理财产品,境外自营机构以FDI形式对境内主体参股、提供技术和资金支持。未来在合适条件下,再试点境外自营机构独资在华经营业务。同时,建议重新启动关于程序化交易监管的研究和立法工作^①,充分汲取伊世顿、司度案件教训,参考国际经验(肖钢,2020),强化对程序化交易,尤其是高频交易的监管力度,构建具有中国特色的证券期货市场高频交易法律监管框架(刑会强,2016)。

①参见《中国证监会就<证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)>公开征求意见》(2015年10月9日)。

第五,从金融稳定角度,境外金融机构在境内不论以何种形式设立实体,不论基于自营需要还是开展代客性质的投资,都应满足境内金融稳定法规(征求意见稿)中关于持牌经营的立法思路。从当前境内期货市场高频交易利润份额看,境外自营机构已成为事实上的主要盈利者,其技术优势和市场占有规模均已明显超过本土投资机构,但这些外商背景的所谓贸易实体目前几乎不受任何跨境金融法规的直接监管。在上位法缺失以及跨境监管协调失效的大背景下,此类实体的存在可能会在极端情形下造成风险跨境传染,尤其考虑到其境外自营机构背景,极可能在极端行情下,通过技术优势、内外盘配合,合谋跨境套利交易,甚至对个别品种控盘等,产生溢出效应影响境内金融稳定。因此,若在《期货和衍生品法》未对境外金融机构境内开展程序化交易准入进行原则性指导的大背景下,正在研究出台的《金融稳定法》可参考欧盟对于衍生品的审慎管理原则^①,从维护整个金融市场稳定的角度,将这类开展纯投机的外商投资实体纳入统一管理。

五、结语

境内期货市场自第二次整顿以后便进入高速发展阶段,上市期货品种数量迅速增长,市场规模扩大,流动性显著改善(姜哲,2021),产生了大量的投机机会,势必会吸引境外投资者的参与。然而中国金融监管部门参考国际上资本项目可兑换的经验教训,将衍生品市场对外开放作为开放次序相对靠后的项目,是基于防范风险的切实需要,也是践行金融稳定的统筹安排。在此背景下,境外自营机构基于现行监管法规存在的漏洞,通过直接设立外商投资企业等方式在境内长期开展以期货自营交易为主的投资行为,虽明显违背境内监管部门对衍生品市场审慎有序开放的初衷,且其二级市场交易所产生的巨额利润已构成客观上的主营业务,可能违反《外商投资法》中的负面清单限制,但结合其复杂的历史发展脉络和现行监管政策存

在疏漏的事实,又不得不承认其存在的合理性。

要稳妥化解相关风险,还应尽快形成风险处置方案,基于跨境期货交易风险管理和业务规范的需要,梳理现有法规,提供司法解释,明确此类业务定性,以行政监管部门发布规范性文件或由自律监管部门发布操作指引形式,禁止增量业务发生,积极处置存量业务,有序引导其与现有的合法入市渠道对接,兼顾境外自营机构准入、国民待遇、策略隐私保护等因素,广开“正门”。中长期来看,要完善上位法,从明晰的准入机制入手,夯实自律监管主体的主动监管责任,兼顾好期货市场发展和金融稳定、资本流动、国家安全、贸易自由化等目标的关系。

[参考文献]

- [1]巴曙松,王一出.高频交易对证券市场的影响:一个综述[J].证券市场导报,2019(7):42-51.
- [2]季烨.国际投资条约中投资定义的扩张及其限度[J].北大法律评论,2011(12):85-108.
- [3]姜洋.期货市场国际化[M].北京:中信出版社,2020.
- [4]姜哲.期货市场国际化:现状、问题与应对[J].证券市场导报,2021(8):12-20.
- [5]姜哲.境内期货市场双向开放问题探讨[J].证券市场导报,2019(4):33-41.
- [6]姜哲.程序化交易的潜在风险和监管体系研究[J].金融监管研究,2017(6):78-94.
- [7]王琦.蚂蚁集团暂缓科创板上市的法律分析[J].银行家,2022(4):129-131.
- [8]肖钢.中国资本市场变革[M].北京:中信出版社,2020.
- [9]刑会强.证券期货市场高频交易的法律监管框架研究[J].中国法学,2016(5):156-177.
- [10]雍晨.证券期货市场的高频交易监管研究[J].金融与经济,2019(2):83-87.
- [11]岳跃,王石玉.中国期市“房间里的大象”:外资高频交易翻云覆雨[J].财新周刊,2022(5):45-52.

^①参见欧盟 MiFID II 对高频交易的限制条款, https://ec.europa.eu/info/law/markets-financial-instruments-mifid-ii-directive-2014-65-eu_en。